

1001308-64.2017.8.26.0097

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo

Magistrado: DANIELLE CALDAS NERY SOARES

Comarca: Buritama

Foro: Foro de Buritama

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... tais valores, configuraria a cobrança sobre o tráfico jurídico, baseado em simples contrato, o que é vedado.

As tarifas questionadas TUSD e TUST, bem como os encargos setoriais, remuneram atividades relacionadas à prestação do serviço de fornecimento pelas redes básica e especial e manutenção do próprio sistema.

São, pois, atrelados aos meios utilizados para a prestação do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Buritama

Foro de Buritama

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Frei Marcelo Manília, 739, Buritama - SP - cep 15290-000

1001308-64.2017.8.26.0097 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1001308-64.2017.8.26.0097

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo

Requerente:

Fernando Ângelo de Souza

Requerido:

Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE CALDAS NERY SOARES

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9099/95.

Fundamento e DECIDO.

O feito reclama julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que os dados trazidos aos autos são bastantes para o conhecimento da questão posta, não havendo necessidade de produzir outras provas, circunstância que vem a dar azo ao princípio da razoável duração do processo (artigos 5º, inciso LXXVIII, da CRFB/88 e 139, inciso II, do diploma processual civil).

Como é cediço, o juiz é o destinatário final da prova, incumbindo-lhe decidir sobre a necessidade, ou não, de dilação probatória mais ampla, ou julgar antecipadamente o pedido. Compete ao magistrado, na condução do processo, deferir e apreciar o arcabouço probatório coligido. Entendendo que as provas constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento para o deslinde da questão, não se configura cerceamento de defesa (artigo 371 do Código de Processo Civil).

Nesse sentido, prevê o artigo 370 do mesmo diploma legal: "Caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito" .

Passo à análise das preliminares.

Não é mais cabível a suspensão do processo por força do IRDR nº 2246948-

26.2016.8.26.0000, porque a suspensão dos processos acerca da matéria afetada se deu em 2017, e o CPC determina que, superado o prazo de julgamento do IRDR, de um ano, cessa a suspensão dos processos, em atenção aos princípios constitucionais da duração razoável do processo, da economia e celeridade processual (CF, art. 5º, inciso LXXVIII; e CPC, art. 4º e 6º). Dessa forma, levante-se a suspensão utilizando o código próprio (55555).

Ademais, ainda que se possa alegar a superveniência de ordem de suspensão determinada no Recurso Especial nº 1.734.902-SP (Tema 986 - STJ), nota-se que a ordem de suspensão foi proferida em 2019. O artigo 1.037, §4º do Código de Processo Civil dispõe que "Os recurso afetados deverão ser julgados no prazo de 1 (um) ano e terão preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus", reprodução quase idêntica à prevista no artigo 980 do CPC, razão pela qual entende-se pela aplicação, por analogia, do previsto no parágrafo único deste artigo.

No mais, antes de adentrar no mérito propriamente dito, impende ressaltar que o julgado recente colacionado (Resp 1.163.020/RS) refere-se à decisão tomada pela 1ª Turma do STJ em apertada maioria (resultado de 3 a 2). Cabe também a observação que não serve de precedente vinculante, haja vista que não fora submetido ao julgamento sob o rito de recursos repetitivos.

Tal fato é relevante, mas não o suficiente para justificar a mudança na orientação deste juízo. Assim, por segurança jurídica, mantém-se a orientação que vinha sendo seguida pelo juízo, enquanto não ocorra mudança clara e definitiva de entendimento, pelo STJ ou pelo STF.

Cabe salientar, ademais, que o TJSP, majoritariamente (ainda que não de modo unânime e pacífico) vem seguindo essa orientação, mesmo após o julgamento do Resp 1.163.020/RS: Ap. 1020567-60.2016.8.26.0071, Rel. Heloísa Martins Minessi, 5ª Câmara de Direito Público, j. 12/05/2017; Ap. 1030834-73.2016.8.26.0562, Rel. Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, j. 09/05/2017; Ap. 1052518-63.2015.8.26.0053, Rel. Bandeira Lins, 8ª Câmara de Direito Público, j. 10/05/2017; Ap. 1038964-52.2016.8.26.0562, Rel. Ana Liarte, 4ª Câmara de Direito Público, j. 08/05/2017.

No mérito, a demanda é procedente.

Trata-se de ação declaratória c/c repetição de indébito, para o fim de afastar da base de cálculo do ICMS a incidência das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD).

Como cediço, o ICMS caracteriza-se como tributo incidente sobre operações relativas à circulação de mercadorias. O fato gerador é a saída do estabelecimento do contribuinte, sendo devido o imposto somente com a entrega ao seu destinatário, quando ocorre a efetiva transferência da posse ou propriedade. O efetivo consumo, pelo destinatário final, é imprescindível para a caracterização do fato gerador do tributo.

Note-se que o ICMS incide sobre as operações relativas à circulação de mercadorias, compreendendo negócio jurídico mercantil. O artigo 1º da Lei Estadual nº 6.374/89 estabelece que:

Artigo 1º - O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incide sobre: (Redação dada ao artigo pela Lei 10.619/00, de 19-07-2000; DOE 20-07-2000) I- operação relativa à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias em qualquer estabelecimento; (...)

O termo "circulação" deve ser entendido, conforme lição de Leandro Paulsen, como "a passagem das mercadorias de uma pessoa para outra, sob um título jurídico, sendo irrelevante a mera circulação física ou econômica" (PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de; Impostos: Federais, Estaduais e Municipais, 9ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p. 253).

Em outros termos, circulação é a mudança da titularidade jurídica do bem, e não a mera movimentação física.

Dessa forma, o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro não configura o fato gerador do ICMS. Nesse sentido, a súmula 166 do Colendo

Superior Tribunal de Justiça: "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". Igualmente não configura fato gerador do ICMS os atos de preparação e produção da mercadoria. Isto porque o conceito de mercadoria corresponde à ideia do bem corpóreo (ampliado constitucionalmente para abranger a energia elétrica, malgrado se trate de bem incorpóreo), resultado da atividade "profissional do produtor, industrial e comerciante, tendo por objeto a sua distribuição para o consumo (...) distinguindo-se das coisas que tenham qualificação diversa, como é o caso do ativo permanente".

Logo, conclui-se que apenas a circulação da mercadoria, como resultado da atividade profissional desenvolvida, é que configura fato gerador do ICMS. O fato gerador, portanto, é a saída do estabelecimento do contribuinte com a entrega ao seu destinatário, momento em que ocorre a efetiva transferência da posse ou propriedade.

Veja-se que o consumo efetivo, pelo destinatário final, é imprescindível para a caracterização do fato gerador do tributo.

Portanto, ainda que a preparação, produção e distribuição sejam etapas para o fornecimento de energia elétrica, certo é que são atividades-meio, e, assim, não podem integrar a base de cálculo para o tributo, na ausência de previsão legal. A incidência sobre tais valores, configuraria a cobrança sobre o tráfico jurídico, baseado em simples contrato, o que é vedado.

As tarifas questionadas TUSD e TUST, bem como os encargos setoriais, remuneram atividades relacionadas à prestação do serviço de fornecimento pelas redes básica e especial e manutenção do próprio sistema.

São, pois, atrelados aos meios utilizados para a prestação do serviço, daí o não cabimento de sua consideração na base de cálculo do tributo.

Nesse sentido:

"ICMS. Energia elétrica. Tarifas de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD) - Inocorrência de hipótese de incidência que admita utilização dessas tarifas na base de cálculo do imposto. Inexistência de "circulação" de mercadoria. Precedentes. Legitimidade ativa para a repetição. Impossibilidade de condenação em pagamento de honorários contratados com advogado. Recurso fazendário improvido, e recurso da empresa autora parcialmente provido." (Apelação nº 1009577- 98.2015.8.26.0053, rel. Des. LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL, j. 14/12/2015).

"APELAÇÃO. Ação Declaratória c.c. Repetição de Indébito. ICMS. Transmissão de energia elétrica Pretensão de afastamento da incidência do ICMS sobre a "Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de energia Elétrica" TUSD e TUST e encargos de conexão Sentença que julgou procedente a demanda Alegação de ilegitimidade ativa e custo operacional do sistema que deve ser suportado por quem o utiliza Pretensão de improcedência da ação - Inadmissibilidade Transmissão e distribuição de energia elétrica que não compõem o fato gerador do ICMS Legitimidade da empresa autora pacificada em recentes decisões do E. STJ Sentença de primeiro grau que será mantida- Recurso desprovido." (Apelação nº 1019266-69.2015.8.26.0053, rel. Des. EDUARDO GOUVÊA, j.11/04/2016).

Aplica-se, ainda, ao caso em análise, a Súmula nº 391 do E. STJ: "O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada".

Na situação dos autos, há circulação econômica com transferência da propriedade da energia elétrica apenas no momento em que esta é efetivamente consumida pelo destinatário, o que não ocorre na fase de transmissão e distribuição, que são meras etapas necessárias à prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica.

Portanto, pelo todo exposto acima, forçoso concluir pela ilegalidade da cobrança do ICMS sobre os valores referentes à TUST e TUSD e demais encargos setoriais, porquanto estão fora do âmbito do tributo.

Sobre o valor a restituir, mister que se adicione correção monetária desde o desembolso de acordo com a Tabela Prática do TJ/SP até o trânsito em julgado e, a partir de então, deverá ser aplicada a taxa SELIC (que abrange os juros de mora e correção monetária), conforme decidido pelo C.STJ no Recurso Especial nº

1.111.189/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 19) e consoante art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ ("Os juros moratórios, na repetição de indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença"), pois, tratando-se de repetição de indébito tributário não tem incidência a Lei 11.960/09.

Os demais argumentos apresentados pela ré não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada por esse julgador (art. 489, inciso IV, do Código de Processo Civil).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por FERNANDO ÂNGELO DE SOUZA em face do FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO para declarar definitivamente a inexistência da relação jurídico-tributária entre as partes que obrigue o autor a proceder ao pagamento do ICMS incidente sobre os valores devidos a título de TUST e TUSD, na instalação elétrica de nº 28583230, definindo-se a base de cálculo do referido tributo como sendo, unicamente, o montante relativo à energia elétrica efetivamente consumida, devendo a ré se abster de praticar medidas coercitivas relativas à referida cobrança. Condene a ré à repetição de indébito pago, devidamente apurado em liquidação de sentença, referente à inclusão na base de cálculo do ICMS dos valores a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD) de energia elétrica das mencionadas instalações, respeitada a prescrição quinquenal e desde que comprovados os respectivos recolhimentos, acrescidos de correção monetária e juros de mora como acima exposto. Sem custas e honorários por expressa disposição legal (artigo 55 da Lei 9.099/95) Ficam os litigantes cientes, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou manifestamente protelatórios sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, sem alterações para as partes, arquivem-se os autos digitais, dando-se baixa no distribuidor. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Buritama, 01 de novembro de 2022.